

CONTRATO DE OBRA

§ 1.– Conceptos generales

396. Concepto y terminología

Se llama contrato de obra al contrato en virtud del cual una de las partes, actuando independientemente, se compromete a realizar una obra, y la otra, a pagar por esa obra un precio en dinero, que se llama retribución (art. 1251).

El Código Civil y Comercial denomina, al que ejecuta la obra, *contratista*, y al que la paga, *comitente*. Es la terminología que seguiremos en nuestro estudio.

397. Caracteres

El contrato de obra presenta los siguientes caracteres:

- a) Es bilateral, pues origina obligaciones a cargo de ambas partes, y por lo tanto, oneroso.
- b) Es de tracto sucesivo, porque sus efectos se prolongan en el tiempo.
- c) Finalmente, es conmutativo, pues se supone que las contraprestaciones recíprocas son proporcionadas.

398. Objeto

Aunque las reglas de nuestro Código han sido pensadas teniendo en mira fundamentalmente la realización de una construcción u obra material, lo cierto es que el contrato de obra es mucho más amplio y alude a las obras más diversas, tales como la construcción de un edificio, puente, camino, etc., su modificación o refacción, y aun su demolición; la fabricación de una máquina o motor, su reparación, su desarme; la realización de obras intelectuales, tales como escribir un libro, una obra de teatro, una partitura, pintar un retrato, hacer una escultura, etcétera.

De acuerdo con las reglas generales relativas a los actos jurídicos (arts. 279 y 1004), ese objeto debe ser posible, lícito, concorde con la moral y las buenas costumbres y, finalmente, determinado.

Sobre este último punto, dispone el artículo 1253 que a falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, el contratista elige libremente los medios de ejecución del contrato. Pero, además, deberá ejecutar el contrato conforme a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el estado del arte, es decir, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada (art. 1256, inc. a)].

399. Los materiales; quién debe aportarlos y a quién pertenecen

La obligación de poner los materiales puede recaer sobre el contratista o el comitente; a falta de previsión sobre el punto, debe aportarlos el primero, salvo que lo contrario resulte de la costumbre del lugar para esa obra o surja de otros elementos de juicio, particularmente el precio. Tal es la solución que aporta el artículo 1256, inciso c). Si han sido aportados por el contratista, le pertenecen hasta el momento de la entrega de la obra; el comitente no podrá reivindicarlos y solo tendrá derecho a reclamar su entrega por vía de acción de cumplimiento de contrato, a menos que se trate de cosas muebles incorporadas como accesorias a otras de propiedad del comitente, en cuyo caso éste adquiere la propiedad desde el momento de la incorporación. Si han sido aportados por el comitente, éste conserva la propiedad sobre ellos, a menos que se trate de cosas fungibles.

A.

— FORMACIÓN DEL CONTRATO

400. Concursos o licitaciones

Ordinariamente, el contrato entre el contratista y el comitente se concluye después de tratativas directas; pero es también frecuente, sobre todo en obras importantes, el llamado a concurso o licitación privada. Ese concurso puede referirse bien a la calidad técnica o artística de la obra, en cuyo caso va normalmente acompañado de la designación de un jurado encargado de discernir el premio, o bien puede el comitente fijar de antemano con precisión todas las características de la obra, licitando solamente su precio. Por lo común estos concursos llevan aparejada la obligación de adjudicar la obra al vencedor; pero también puede ocurrir que el comitente se reserve el derecho de no encargar la obra a ninguno, y aun la de pasar sobre la oferta mejor y adjudicarla a otro que le merezca mayor confianza por su solvencia o capacidad técnica.

401. Forma

La ley no prescribe forma alguna para el contrato de obra, que queda concluido por el simple consentimiento, sea verbal o escrito. Solo por excepción, el contrato de obra subsumida en la ley de defensa del consumidor, deberá instrumentarse por escrito y conforme a presupuesto previo (arts. 2º y 4º, ley 24.240).

402. Prueba

A falta de disposiciones especiales sobre el punto, rigen las reglas generales respecto de la prueba de los contratos (art. 1019). El contrato de obra puede probarse por cualquier medio, en tanto es de costumbre que el mismo se instrumente por escrito.

Un problema de prueba muy frecuente se presenta respecto de los llamados adicionales ordenados verbalmente por el comitente, que no figuran en el contrato originario. La jurisprudencia ha resuelto que en estos casos basta con el acuerdo tácito y que ese acuerdo se presume cuando el comitente recibe la obra sin reservas.

403. Documentación complementaria; hipótesis de contradicción entre distintas cláusulas

Los contratos de obras materiales –particularmente si son importantes– suelen acompañarse de una documentación complementaria (pliegos de condiciones generales y particulares, presupuestos, planos generales y detalles, etc.); todos ellos forman parte del contrato.

Como estos documentos son extensos y numerosos, no es difícil encontrar contradicciones entre sus cláusulas. El problema debe ser resuelto por el juez, de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso, y según las normas interpretativas que hemos estudiado en otro lugar. Solo deseamos considerar aquí un supuesto específico referido a este contrato. Los pliegos de condiciones suelen incluir numerosas cláusulas-tipo habituales en todos los contratos análogos. Si luego resulta una contradicción entre ellas y otras disposiciones del contrato, en principio hay que admitir que es esta la que expresa la verdadera voluntad de las partes, pues es lógico pensar que la cláusula-tipo ha sido incorporada mecánica e irreflexivamente al acuerdo. Sin perjuicio de que del contexto del contrato, interpretado en su conjunto, pueda resultar una conclusión diferente.

B.— DISTINTOS SISTEMAS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

404. Sistemas más comunes en la ejecución de obras materiales

El Código Civil y Comercial ha regulado entre los artículos 1262 y 1266 los sistemas a los que puede ajustarse la ejecución de una obra material; siguiendo para ello, los estipulados en la ley de obras públicas.

Ambas normas refieren que las contrataciones pueden ser ejecutadas por unidad de medida, por coste y costas, o por ajuste alzado, sin perjuicio de otros sistemas de contratación que se establezcan (art. 1262; art. 5º, ley 13.064). Son estos los sistemas más frecuentes también en las contrataciones privadas. Veámoslos:

a) Ajuste alzado

La obra se contrata por ajuste alzado, también llamado retribución global, cuando las partes establecen desde el comienzo un precio fijo e invariable. Las modificaciones en el precio de los materiales o de la mano de obra benefician o perjudican al contratista y no alteran el precio. A veces el propietario se compromete a reconocer ciertas

alteraciones en el precio, dentro de límites tope; es lo que se llama ajuste alzado relativo, por oposición al *común* o *absoluto*, en el que no hay variación de ninguna naturaleza. A su vez, el artículo 1255 señala que si opta por este sistema en forma absoluta, las partes renuncian a petitionar reajuste alguno sobre el precio, salvo que procediere la invocación de la excesiva onerosidad sobreviniente.

b) Por unidad de medida

El precio se fija por medida o por unidades técnicas; por ejemplo, por kilómetro de camino. Aquí no se fija el precio total, que empero, es también invariable como en el caso anterior, pues resulta de multiplicar el número de unidades encargadas por el precio fijado a cada una de ellas. Así, por ejemplo, se contrata la construcción de un camino de cincuenta kilómetros, fijándose el precio en una cantidad determinada de pesos el kilómetro. Estos contratos dejan la puerta abierta para que las partes puedan continuar la obra emprendida en las mismas condiciones si el contrato sigue siendo conveniente para ambas. Basta en tal caso una simple orden del comitente, sin que sea necesario formalizar un nuevo contrato con nuevas y completas estipulaciones. Al igual que con el sistema de *ajuste alzado* las partes no podrán pedir reajustes sobre el precio pactado, salvo que mediere un hecho que justifique la aplicación de la teoría de la imprevisión (art. 1255).

c) Por coste y costas

El precio de la obra se fija teniendo en cuenta lo que ella costaría de mantenerse los actuales precios de los materiales y salarios; pero se reconoce al contratista el derecho de reajustarlo de acuerdo con la variación de aquellos. Esta contratación admite dos modalidades: o bien el aumento se limita estrictamente a los rubros indicados (materiales y mano de obra) sin afectar la retribución reconocida al contratista que se mantiene invariable, o bien se reconoce también un aumento de gastos generales y retribución proporcional al aumento que en su conjunto han experimentado los materiales y la mano de obra. Agreguemos todavía, que el contratista no podrá pretender aumentos que se hayan producido después de vencido el plazo en que debió terminar la obra, pues en esta hipótesis, el perjuicio se ha originado en su incumplimiento; salvo, naturalmente, que pruebe que la demora se ha originado en un caso fortuito o fuerza mayor.

Ahora bien, como regla, si la obra se contrata por el sistema de ejecución a coste y costas, la retribución se determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos o indirectos (art. 1263).

Se comprende que, desde el punto de vista del comitente, el sistema más conveniente es el de ajuste alzado o por unidad de medida, pues así queda a cubierto de sorpresas; inclusive, no deja de tener sus ventajas desde el punto de vista del contratista, pues como el sistema inspira mayor confianza, le será más fácil contratar

con un margen mayor de beneficio. Pero la inflación ha impuesto hoy en toda obra importante y de duración prolongada, el sistema de coste y costas. Si no es sobre la base del reconocimiento del aumento de los materiales y la mano de obra, los contratistas no pueden afrontar un contrato que para ellos se haría muy aleatorio; y a los comitentes les asegura que el contratista solo tendrá una ganancia razonable calculada en función del valor real de la obra. En suma, la construcción por ajuste alzado y por unidad de medida es más conveniente en épocas de estabilidad económica; el de coste y costas en períodos de inflación.

d) Contratos separados

También puede el comitente de la obra suscribir contratos separados para la realización de las distintas partes de una misma obra; así, por ejemplo, a una empresa encarga la demolición, a otra la estructura de hormigón, a otra la obra de albañilería, a otra los sanitarios, etc. Se trata de contratos independientes unos de otros.

e) Subcontratos

Es también posible que la obra se haya encargado a una sola empresa y que esta subcontrate por su cuenta los distintos aspectos de la construcción. En este caso, el contratista principal pasa a ser comitente de la obra respecto de los subcontratistas que están vinculados con él. En este sentido, el Código autoriza expresamente al contratista a valerse de terceros para la ejecución de la obra (excepto que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personalmente), pero si lo hiciere, mantiene el deber de dirección frente a estos y la responsabilidad frente al comitente (art. 1254).

II – OBLIGACIONES DE LAS PARTES

§ 1.– Obligaciones del contratista

405. Enumeración

Conforme al artículo 1256, las obligaciones del contratista consisten en:

a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;

b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida;

c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos;

d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer; y,

e) ejecutar la obra en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.

Asimismo, el contratista debe permitir el ejercicio del control de la obra por parte del comitente (art. 1269).

Finalmente, el contratista y todos los profesionales que hayan intervenido en la obra, o hayan ejercido funciones asimilables a aquél, responden ante terceros por los daños que les resulten de la inobservancia de leyes y reglamentos o de otros hechos ilícitos (arts. 1273, 1274 y 1277). Esta responsabilidad no surge del contrato sino de la ley.

A.

— OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LA OBRA

406. Modo de ejecución: principio general

La obra encargada debe ejecutarse, en primer término, siguiendo las estipulaciones del contrato. Es que, toda vez que el comitente contrata la obra en su propio interés, no puede el contratista ejecutarla apartándose de las previsiones contractuales pactadas.

Ahora bien, en el cumplimiento de las estipulaciones acordadas, el contratista, en tanto experto en su arte u oficio, debe seguir las denominadas *reglas del arte*, las cuales no solo se refieren a la calidad de la obra, su seguridad, estabilidad y aptitud para servir a su destino, sino también a su forma y estética. Es claro que si en el contrato se ha especificado detalladamente la forma en que ha de cumplirse el trabajo, la calidad de los materiales, etc., habrá que estar a lo que allí se indique; las dificultades suelen presentarse cuando no se ha previsto el punto o se lo ha previsto deficientemente.

a) Falta de estipulación

A falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, el contratista o prestador de los servicios elige libremente los medios de ejecución del contrato (art. 1253). El precio será en estos casos un elemento de juicio esencial para apreciar la justicia de las exigencias del comitente; pues si solo ha pagado, por ejemplo, lo que puede ganar un albañil, no es justo que exija la prolijidad y perfección que cabría exigir de la obra dirigida por un arquitecto.

Asimismo, entendemos que el legislador al dejar librado al criterio del contratista la elección de los medios para la ejecución del contrato, ha ponderado su condición de profesional en la materia; en virtud de lo cual, a la hora de valorar su responsabilidad por las consecuencias de dicha elección, el *standard* de juicio deberá ser mayor (art. 1725).

b) Obra que debe realizarse a satisfacción del comitente

A veces los contratos de obra incluyen una cláusula según la cual los trabajos deben realizarse a *satisfacción del comitente o de un tercero*; tal estipulación no autoriza al comitente (o, en su caso, al tercero) a rechazar arbitrariamente la obra, ni a tener exigencias excesivas. El artículo 1634 del Código Civil velezano decía que, en dicho supuesto, la obra se entiende reservada a la aprobación de peritos, solución que entendemos sigue siendo aplicable en atención a la regla prevista en el artículo 1068. En efecto, esta norma establece que si persistiesen las dudas respecto de la interpretación del contrato, y éste fuese oneroso, habrá que estar al sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes, equidad esta que surgirá del informe pericial.

407. Ejecución de la obra por intermedio de terceros

Salvo que el comitente haya tenido en mira las condiciones personales del contratista, éste está autorizado a realizarla, ya sea personalmente, ya sea por intermedio de obreros dependientes de él, ya sea, en fin, por subcontratistas, manteniendo el deber de dirección y la responsabilidad sobre estos terceros (art. 1254).

408. Sanciones por incumplimiento de esta obligación

El dueño de la obra o comitente está protegido contra el incumplimiento o el cumplimiento deficiente de la obligación de ejecutar la obra, con los siguientes derechos y acciones:

a) Derecho a no pagar el precio

Ante todo, el comitente puede negarse a pagar el precio, invocando la excepción de incumplimiento. Es claro que no todo defecto, por pequeño que sea, autoriza al comitente a no pagar. No lo está si los defectos son de detalles o si son susceptibles de reparación por una suma insignificante con relación al monto total de la obra. Ello, sin perjuicio del derecho a exigir la reparación de las deficiencias y de retener las sumas necesarias para ese objeto.

b) Acción por cumplimiento del contrato y reparación de daños

Es, desde luego, la acción propia y primera derivada de todo incumplimiento contractual. El reclamo por los daños sufridos debe comprender tanto el daño emergente como el lucrocesante.

c) Acción por resolución del contrato

El comitente puede pedir la resolución del contrato en caso de incumplimiento del contratista. En los artículos 1083 y 1084 del Código Civil y Comercial se reconoce a cualquier contratante el derecho a tener por resuelto el contrato si requerida a cumplir la otra parte, no lo hiciera dentro del plazo de quince días, salvo que los usos y

costumbres fijaren uno menor.

Es oportuno recordar las ventajas de la cláusula resolutoria expresa en el contrato tiene la ventaja de que en tal caso no es necesario el requerimiento ni se concede al otro contratante la oportunidad de cumplir: el mero vencimiento del plazo puede producir la resolución del contrato de pleno derecho (art. 1086).

Pero es necesario agregar que no cualquier incumplimiento, por mínimo que sea, permite tener por resuelto el contrato: el incumplimiento debe ser grave (art. 1084).

d) Derecho a hacer ejecutar la obra (o repararla) por un tercero

Si el contratista falta definitivamente a su obligación de hacer la obra, el comitente tiene derecho a hacerla ejecutar (o reparar) por un tercero a costa del contratista; es esta una simple aplicación de la norma general del artículo 730. Pero este recurso no podrá utilizarse si la obra ha sido encargada teniendo en mira las calidades personales del contratista; tal como ocurriría en el retrato encargado a un pintor.

El contratista no solo estará obligado a indemnizar el justo precio pagado al tercero, sino también los otros daños derivados del incumplimiento, tales como los trastornos y gastos derivados del retardo en la ejecución, etcétera.

e) Derecho a destruir la obra mal ejecutada

Cuando la obra se ha realizado deficientemente, el comitente podrá tenerla por no hecha y destruir lo que se hubiera hecho mal (art. 775). Es una sanción dura que la ley establece como poderoso acicate para que los contratantes cumplan cabalmente sus obligaciones. Pero no cualquier deficiencia permite al comitente tener por no hecha la obra y destruirla.

Si los defectos no son sustanciales, tal conducta sería abusiva y conduciría a una destrucción de bienes que a la sociedad le interesa evitar. Solo una deficiencia esencial y no reparable, autoriza al comitente a seguir este procedimiento extremo. Si no tuviera esa gravedad, el comitente deberá apelar a otros recursos: negativa a pagar el precio proporcional a esas deficiencias, hacer ejecutar las reparaciones por un tercero por cuenta del contratista o demandar a éste por los daños sufridos.

B. — INFORMAR AL COMITENTE SOBRE LOS ASPECTOS ESENCIALES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN COMPROMETIDA

409. Alcances del deber de información

El legislador, como ya hemos dicho, ha tenido presente la condición de profesional en su tarea que tiene el contratista. Frente a esta situación, se impone la existencia de una desigualdad real con el comitente, quien no posee dichos conocimientos. Para restablecer el equilibrio resulta esencial, entonces, imponer un fuerte deber de información sobre el contratista, que no solo abarca el dar a conocer las ventajas y

desventajas de un proyecto, sino también sus costos. Además, asume un deber de consejo al comitente, e, inclusive, debe abstenerse de ejecutar la obra si ella no cumple con los requisitos de seguridad o puede ser dañosa para terceros.

Rigen además, respecto de este deber de información, las mismas regulaciones que la doctrina ha establecido como necesarias para tener por acreditado su cumplimiento:

a) Carga de la prueba

La prueba del cumplimiento del deber de información recae sobre quien está obligado a proporcionarla; en este caso, el contratista. A tales fines, resulta determinante la prueba por escrito.

b) La información debe ser veraz y eficaz

El contratista no solo debe dar información certera, sino que debe ser presentada en forma tal que el comitente pueda comprenderla y emplearla para tomar decisiones al respecto.

La omisión del contratista de cumplir con este deber lo hará responsable por todos los daños causados al comitente, impidiéndole además reclamar mayores costos o eximirse por riesgos que no han sido informados.

C. — *PROVEER LOS MATERIALES ADECUADOS Y NECESARIOS*

410. Alcances

En principio, los materiales para la ejecución de la obra han de ser aportados por el contratista. Es más, el artículo 1262, *in fine*, señala que si las partes no aclaran lo contrario, debe presumirse dicho aporte.

Esta obligación, de la que puede ser dispensado (art. 1256, inc. c)], tiene su sustento en reafirmar la autonomía del contratista respecto del comitente; en tanto, en algunos supuestos, la provisión de materiales podría inferir no un contrato de obra, sino una relación de empleo.

Tal como dice la norma citada, los materiales proveídos por el contratista deben ser adecuados para la ejecución de la obra, respondiendo éste por su mala calidad, como veremos en el número 757.

D. — USAR DILIGENTEMENTE LOS MATERIALES PROVISTOS POR EL COMITENTE E INFORMARLE SI ESOS MATERIALES SON IMPROPIOS

411. Alcances de la obligación

En el caso en que los materiales sean provistos por el comitente, el contratista debe emplearlos en forma diligente, siendo responsable por la destrucción de ellos, de mediar negligencia o dolo. Sin embargo, si la destrucción se produce por caso fortuito antes de la entrega, la responsabilidad es de quien proveyó el material (art. 1258).

Si bien el artículo 1256, inciso d), impone un deber de información sobre el contratista, pues debe anotar al comitente de los vicios del material que éste debiese conocer o de su inadecuación para la obra; el contratista que desconfíe de los materiales debe además abstenerse de emplearlos.

Esta cuestión la veremos con más amplitud cuando analicemos la responsabilidad del contratista por ruina de la cosa (nros. 757 y ss.).

E. — OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA COSA EN EL PLAZO CONVENIDO

412. Plazo pactado y no pactado

Cuando el contrato fija el plazo de entrega, el contratista debe atenerse a él y es responsable de los daños causados por su demora.

El plazo puede ser expreso o tácito; habrá plazo tácito cuando esté sobrentendido por las circunstancias, como si se contrata la construcción de palcos o gradas para ser utilizados en una ceremonia de fecha determinada.

Puede ocurrir también que no exista plazo expreso ni haya más elementos para fijar el plazo tácito que el tiempo razonable para concluir la obra. En tal caso, esa pauta (la del tiempo razonable para terminar la obra) es la que deberá tenerse en cuenta (art. 1256, inc. e)).

Adviértase que el texto no establece la posibilidad de peticionar al juez la fijación de un plazo, como lo hacía el Código Civil velezano; sin embargo, de considerarse una obligación de tiempo indeterminado, esta facultad se encuentra conferida en el artículo 877. En verdad, en la obra existe siempre un plazo tácito, que resulta de la necesidad que se tenga de la cosa o del tiempo razonable para ejecutarla; por lo tanto, el comitente puede interpelar directamente al contratista, o bien pedir la fijación judicial del plazo, si no quiere exponerse a que se repunte que la interpelación ha sido prematura. En otras palabras, el contratista tiene una opción entre estas dos vías.

413. Plazo inicial

Frecuentemente los contratos de obra establecen un plazo para la iniciación de los trabajos y para la terminación de las distintas etapas de la obra. En caso de que el contrato no contuviera tales cláusulas, debe entenderse que el contratista está obligado a iniciar la obra de inmediato o tan pronto se lo permita la adquisición de los materiales. Igualmente, tiene la obligación de continuar los trabajos con una actividad razonable, enderezada al cumplimiento del plazo final.

414. Modificación del plazo; trabajos adicionales

Nada se opone a que las partes modifiquen, en el curso del contrato, el plazo fijado originariamente. El plazo debe considerarse tácitamente prorrogado en el caso de que el comitente ordene trabajos adicionales, a menos que se demuestre que para llevarlos a cabo no era necesaria ninguna prórroga.

415. Término supletorio no contractual

Se vincula estrechamente con el tema tratado en el número precedente, el del plazo *supletorio*. Se llama así al que goza el contratista por un hecho que no le es imputable; como ocurre si ha debido suspender las obras por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho del propio comitente; así sucede cuando el comitente demora la entrega de planos o de materiales o se retrasa en los pagos parciales prometidos. En tales casos, el plazo debe considerarse prorrogado por todo el tiempo que duró el impedimento para continuar los trabajos, y no será necesaria la fijación por el juez. Todo ello sin perjuicio del derecho del comitente de demostrar que su demora no justifica la paralización de las obras ni la concesión de un plazo supletorio.

Cabe señalar sobre este "tiempo supletorio", que es de uso en los contratos de obra establecer un tope para el mismo, asignando, por ejemplo, la cantidad de días que se imputarán como retardo por "lluvia"; entendiéndose que retardos superiores a los pactados, serán considerados imputables al contratista y pasible de la aplicación de las penalidades previstas en el contrato.

416. Término insuficiente

Puede ocurrir que se haya fijado un término en el cual sea imposible cumplir la obra. Esa sola circunstancia no anula el contrato, pues el plazo no es generalmente determinante de la obligación. Ninguna de las partes podría desligarse del contrato aduciendo la imposibilidad de cumplir con el objeto en el tiempo fijado y, en caso de divergencia, habrá que pedir la fijación judicial de una prórroga.

417. Sanciones para el caso de incumplimiento del plazo

En caso de incumplimiento del plazo, el comitente tiene a su disposición los siguientes recursos y acciones:

a) Acción de reparación de daños

El comitente podrá reclamar del contratista todos los perjuicios ocasionados por la demora, particularmente los que resulten del mayor costo de la obra.

b) Abandono de la obra

Si la demora en realizar los trabajos es tal que resulta evidente que no se podrá concluir la obra sino con gran retraso, el comitente tiene derecho a considerar que hay un abandono de la obra y puede reclamar la resolución del contrato y, como consecuencia, la devolución de las cosas que son de su propiedad, además de la reparación de los daños sufridos; igualmente, tiene derecho a hacer ejecutar la obra por un tercero a costa del contratista, de acuerdo con el principio del artículo 730, inciso b).

Es claro que el mero incumplimiento de los plazos parciales o la presunción razonable de que la demora hará imposible la conclusión en término, no autoriza a tener por abandonada la obra y a resolver el contrato. Esto sería una sanción excesiva y abusiva. Es necesario un retraso grave. El abandono es, pues, un concepto flexible, que los jueces deben utilizar prudentemente.

c) Penalidades contractuales

Es de uso en los contratos de obra para la construcción de inmuebles, que se estipulen multas y penalidades a favor del comitente por cada día de retardo en la entrega de la obra, luego de vencido el plazo de entrega pactado, más los días supletorios que correspondan adicionar. Dichas penalidades se rigen por las normas de la cláusula penal, y por lo tanto podrán ser revisadas y, en su caso, morigeradas por el juez si ellas fueren abusivas.

418. Obligación de entregar la cosa; recursos del comitente

El contratista no solo debe concluir la obra en el plazo pactado; está también obligado a entregarla y, en verdad, esto es lo que al comitente esencialmente le interesa.

En el supuesto en que el contratista no entregare la obra, el comitente tiene los siguientes recursos:

a) Si los materiales son de propiedad del contratista (véase nro. 733), el comitente puede reclamar la cosa por vía de cumplimiento de contrato.

b) Si los materiales pertenecen al comitente, éste tiene, además de la acción por cumplimiento, la reivindicatoria, esté o no concluida la obra.

Si al encargar la obra el comitente hubiera hecho entrega de planos, dibujos, descripciones u otros documentos análogos, el contratista está obligado a devolverlos al tiempo de la entrega de la obra.

419. Lugar de la entrega

Puesto que no hay reglas específicas sobre el punto, se aplican los principios generales: a falta de lugar designado en el contrato, la entrega de la obra hecha sobre un cuerpo cierto y determinado, se hará en el lugar en que éste existía al tiempo de

contraerse la obligación y, en su defecto, en el domicilio del deudor al tiempo de cumplimiento de la obligación. Va de suyo que si la obra se realiza sobre un inmueble, la entrega se hará en el lugar en que éste se encuentre ubicado, aunque nada se hubiera indicado en el contrato.

*F. — OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL DEL DESARROLLO DE LA OBRA POR EL
COMITENTE*

420. El derecho de control

Se ha dicho ya que el contratista tiene la obligación de realizar la obra de acuerdo con las *reglas del arte*; debe además, cumplir los trabajos de manera continua y siguiendo un ritmo que normalmente permita concluir la obra en el término pactado; a veces suelen fijarse plazos de comienzo y de finalización de etapas. Todo ello pone de relieve la necesidad de reconocer al comitente el derecho a verificar cómo se va desarrollando la ejecución de la obra. Pues si solo tuviere tal derecho en el momento de la entrega, los perjuicios serían muchas veces irreparables.

El derecho de verificar se encuentra contemplado en el artículo 1269, y la única limitante que se prevé es que no puede ejercerse de una manera tal que entorpezca el avance la obra.

Los gastos de la verificación corren por cuenta del comitente.

Ordinariamente, la verificación de los materiales se lleva a cabo por intermedio del director de obra.

421. Consecuencias de la aceptación o rechazo de los materiales y trabajos

Si durante la realización de la obra, el comitente ha dado su aceptación expresa a los materiales empleados y a la forma como se han desarrollado los trabajos, no podrá en adelante aducir que la realización de la obra no se ajusta a las reglas del arte, ni pretender que se empleen otros materiales de mejor calidad, pero subsiste siempre la responsabilidad del contratista por ruina de la obra.

Puede ocurrir también que el comitente *rechace* los materiales. Si en el contrato se ha previsto tal supuesto, habrá que estar a lo pactado; pero toda divergencia acerca de si los materiales empleados tienen o no la calidad prevista en el contrato, debe ser decidida judicialmente y no podría quedar librada al arbitrio del comitente. Si el contrato nada ha previsto sobre el punto, el comitente disconforme con la calidad de los materiales empleados o la mala ejecución de la obra, puede demandar judicialmente la resolución del contrato.

1.— Responsabilidad por destrucción o deterioro de la cosa durante la ejecución

422. Caso en que el comitente pone los materiales

La responsabilidad del contratista frente al comitente debe analizarse en relación a distintos supuestos:

a) Destrucción o deterioro por caso fortuito

Si la cosa se destruye antes de ser entregada; y el contratista no ha provisto los materiales, solo tendrá derecho a una retribución equitativa por la tarea realizada (arg. art. 1268, inc. a)).

b) Destrucción por mala calidad de los materiales

Si la destrucción se ha originado en la mala calidad de los materiales o en que eran inapropiados para el empleo que se les dio, el contratista responde ante el comitente, por más que sea éste quien los hubiera proveído (art. 1268, inc. b)). Este principio se explica fácilmente, pues siendo el contratista el experto, tenía la obligación no solo de advertir al comitente, sino también de abstenerse de emplear los materiales defectuosos.

c) Destrucción por vicios ocultos de los materiales

Si la destrucción o deterioro de la cosa se debe a los vicios ocultos de los materiales proveídos por el comitente, el contratista carece de toda responsabilidad y conserva su derecho a la retribución. Es justo que así sea, porque en ese caso no hay culpa de su parte. La responsabilidad por la destrucción será del enajenante de los materiales, así como también del fabricante.

423. Caso en que el contratista pone los materiales

En este caso la solución es clara conforme al artículo 1268, inciso a), si la cosa se pierde por caso fortuito antes de la entrega y la obra se hace en un inmueble del comitente, el contratista tiene derecho al valor de los materiales y a una suma equitativa por las tareas ya realizadas.

Si la pérdida se debiera a la mala calidad de los materiales usados, deberá indemnizar al comitente de todos los daños que le resulten (art. 1268, inc. b)).

Si la obra se ha destruido por una causa de fuerza mayor después de haber sido puesto en mora el comitente para recibirla, el contratista tiene derecho a percibir íntegramente la remuneración pactada (arts. 1268, inc. c)).

2.— Responsabilidad después de entregada la obra

424. Ruina por vicios del suelo

La circunstancia de que la ruina se haya originado en vicios del suelo no exime de responsabilidad al arquitecto proyectista, ni al constructor, ni al director de obra, todos los cuales son responsables en forma concurrente; es decir, cada uno de ellos por el total frente al comitente, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran caber entre ellos (arts. 1273 y 1274).

En caso de ruina por esta causa, la responsabilidad primaria corresponde al proyectista, cuyo deber es estudiar la calidad del suelo para calcular una estructura suficientemente segura. Por consiguiente, el director de obra, o el constructor que hubieran indemnizado al comitente, podrán ejercer contra él la acción de regreso, a menos que los vicios sean tan notorios que no pudieran escapar a la atención de un constructor diligente. Estas reglas se aplican tanto a la ruina ocurrida durante la ejecución de la obra, como después de cumplida.

425. Regla legal

Las responsabilidades del contratista no terminan con la entrega de la obra. La buena fe exige que garantice la bondad del trabajo realizado y los materiales empleados. A ello se debe la disposición del artículo 1273 según el cual *el constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena.*

La norma transcripta ha seguido las huellas del artículo 1643 del Código Civil de Vélez, luego de la reforma de la ley 17.711, aunque con una terminología más abarcativa. La responsabilidad del contratista de una obra realizada en un inmueble destinada a tener una larga duración abarca los daños que comprometen su solidez o la hacen impropia para su destino. Y solo se libera por una causa ajena, la que nunca puede estar constituida por el vicio del suelo o de los materiales.

426. Ruina de la cosa

¿Qué debe entenderse por *ruina total o parcial* de la cosa? No es necesario un derrumbe o destrucción de la cosa; basta con un deterioro importante. Este deterioro, ha entendido la jurisprudencia, puede constituirse por el cúmulo de defectos o vicios. Más aún, no es indispensable que la ruina se haya producido, siendo suficiente con que exista un peligro cierto e inmediato de que se produzca.

Tampoco importa que la ruina provenga de vicios de la construcción o de mala calidad de los materiales o de los vicios del suelo. En cualquier caso, la ley hace responsable al contratista. Si se trata de vicios de la construcción, porque su culpa es directa e inexcusable. Si de vicios del suelo perteneciente al comitente, porque el contratista tiene la obligación de cerciorarse de la calidad del suelo y de su aptitud para recibir la carga del edificio. Si la ruina se ha originado en la mala calidad de los materiales, el contratista responde porque debió cuidar que fueran adecuados a la obra; no exime la circunstancia de que los haya aportado el comitente, pues él tenía la obligación de rechazarlos. Tampoco queda el contratista excusado de responsabilidad por la circunstancia de haber prevenido al comitente de la mala calidad de los materiales o del suelo.

427. Plazo de garantía

El Código Civil de Vélez no establecía ningún término a la obligación de garantía. La ley 17.711 había llenado este vacío, disponiendo que la responsabilidad cesa después de diez años de recibida la obra (art. 1646). El Código Civil y Comercial ha impuesto un plazo de caducidad de igual término que se computa desde la aceptación de la obra (art. 1275).

428. Defectos aparentes y ocultos

Sobre la responsabilidad del contratista respecto de los defectos aparentes y ocultos, véase número 797.

3.— Reglas comunes a la ruina anterior o posterior a la entrega

429. La responsabilidad del contratista es contractual

Aunque alguna vez la cuestión fue discutida, hoy hay acuerdo general en que la responsabilidad derivada de la ruina de la cosa tiene carácter contractual, nacida de una deficiencia en la manera de cumplir las obligaciones contraídas en el contrato de obra. Si bien el artículo 2561 habla de la prescripción de las acciones de responsabilidad civil, resulta ilógico que se establezcan plazos prescriptivos diferentes para la acción de cumplimiento contractual y para el pedido de reparación de los perjuicios derivados del incumplimiento. Claramente, la responsabilidad civil del contratista es derivada del incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas; en tanto los daños, son la consecuencia de dicho incumplimiento. Por ello, entendemos que el texto del artículo 2561 remite a las acciones de responsabilidad de origen extracontractual, mientras que las acciones de cumplimiento contractual, o de resolución y pedido de reparación de daños, se rigen por el plazo de cinco años.

430. La responsabilidad es de orden público

Antes de la sanción de la ley 17.711 se discutía si la responsabilidad derivada de la ruina era o no de orden público, aunque predominaba la opinión afirmativa. Esta solución ha sido expresamente consagrada por esa ley que –modificando el artículo 1646 del Código Civil de Vélez– establecía que *no será admisible la dispensa contractual* de responsabilidad por ruina total o parcial. Es la buena solución. Estamos de acuerdo con este punto de vista. Una cláusula contractual que eximiese al contratista de toda responsabilidad por la ruina de un edificio, puente, camino, dique, etc., sería notoriamente contraria a la seguridad pública; importaría liberarlo de obligaciones profesionales que se fundan en razones de orden público y allanarle el camino para cumplir su cometido desaprensivamente, con negligencia o mala fe antisociales.

En consecuencia, las cláusulas que eximen o disminuyen la responsabilidad del contratista son nulas, pero nada impide agravar contractualmente dicha responsabilidad.

Bien entendido que esta disposición solo es aplicable a los edificios y otras construcciones hechas sobre inmuebles; si, en cambio, se trata de obras realizadas en cosas muebles (escultura hecha sobre mármol, piedra, bronce; pintura sobre tela, cartón, etc.) no juega en el contrato ningún interés de orden público y, por lo tanto, nada se opone a la validez de las cláusulas de exención de responsabilidad por deterioro o pérdida.

Lo hasta aquí expuesto ha sido receptado en el Código Civil y Comercial que, en el artículo 1276, declaró la nulidad de toda cláusula de exoneración de responsabilidad del contratista y demás participantes en una obra sobre un inmueble, que esté destinada a perdurar en el tiempo o –añade– que la haga impropia para su destino.

431. Carga de la prueba

Producida la ruina de la cosa, se presume que ella se ha originado en defectos de construcción o de mala calidad de los materiales. Vale decir, el comitente no tiene que probar la culpa del contratista; y si éste pretende liberarse de la responsabilidad, debe demostrar que se ha producido por caso fortuito o por culpa del comitente (uso inadecuado, excesivo, peligroso, etc.).

432. Responsabilidad del arquitecto

El arquitecto o ingeniero que hace los planos o dirige la obra tiene una responsabilidad distinta de la del constructor, que debe considerarse en relación a tres hipótesis distintas:

a) El arquitecto solo hizo los planos

En tal caso responde por los errores o vicios de los planos, por los errores de cálculos en la resistencia de las estructuras de hormigón u otro material, por no haber previsto las fallas o falta de solidez del suelo, por falta de cumplimiento de las reglamentaciones

municipales; pero no por defectos de ejecución y mala calidad de los materiales empleados.

b) Hizo los planos y dirigió la obra

Además de la responsabilidad que le compete como autor de los planos, responde también por los vicios de ejecución y por la calidad de los materiales.

c) Dirigió la obra según planos ajenos

Como principio, debe admitirse que tiene la misma responsabilidad que en el supuesto anterior. Con respecto a la calidad de los trabajos y materiales, ninguna duda cabe, pues esta es la responsabilidad específica del director de obra. Pero también responde por los vicios o defectos de los planos, pues por su carácter profesional, no debían pasarle inadvertidos; su obligación era ponerlos en conocimiento del proyectista y del comitente. Por excepción, debe considerarse que carece de responsabilidad cuando los planos cuya ejecución se le ha encomendado implican una alta especialización que no debe esperarse de cualquier profesional; tal, por ejemplo, si se trata del cálculo de resistencia de una estructura audaz, como puede ser un puente colgante, una bóveda de gran abertura, etcétera.

433. Responsabilidad común del arquitecto y del constructor

Frente a este supuesto, el legislador ha querido dejar indemne al comitente, evitándole tener que probar cuál ha sido la causa exclusiva de la ruina. Es por ello, que el artículo 1274, inciso c), ha estipulado una responsabilidad concurrente (arts. 850 y 851) entre el contratista y todos los intervinientes (subcontratistas, proyectistas, director de obra y cualquier otro profesional ligado a la obra), por lo que quedarán todos igualmente obligados frente al comitente, sin perjuicio de las acciones de reintegro.

434. Distribución de la carga de la indemnización

Si frente al comitente, el proyectista, el director de obra y el constructor son responsables cada uno por el todo, ¿cómo se distribuye luego entre ellos la carga de la indemnización? El problema es delicado porque la culpa respectiva puede asumir muchos matices de gravedad. En la doctrina no se ha logrado encontrar una directiva satisfactoria sobre este punto; los jueces habrán de resolver el problema de acuerdo con las circunstancias del caso y teniendo en cuenta la gravedad de las culpas respectivas. Y si estas fueran equivalentes o si no se probara la medida de la culpabilidad de cada uno, habrá que distribuir el peso de la indemnización por partes iguales. Va de suyo que si el contrato de obra ha sido suscrito por un contratista que se ha encargado al propio tiempo de la confección de los planos y la dirección de obra, el único responsable ante el comitente es el contratista; si éste ha subcontratado la confección de los planos o la dirección de obra o la construcción, los subcontratistas serán a su vez responsables ante él.

435. Caducidad y prescripción

El artículo 1275 establece un plazo de caducidad de la acción de 10 años, esto es que si la ruina se produce luego de dicho lapso, el contratista queda liberado. Producida la ruina total o parcial dentro de dicho tiempo, el plazo de prescripción de la acción es de un año a contar desde que se produjo la ruina (art. 2564).

4.— Responsabilidad por el hecho de las personas ocupadas en la obra

436. Disposición legal

Establecía el artículo 1631 del Código Civil de Vélez que el contratista es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupe en la obra. En realidad era innecesario decirlo, pues el contratista asumía, igual que ahora, la responsabilidad de realizar la obra conforme a las reglas del arte; responde por el resultado, y si éste no se logra o se logra defectuosamente, debe indemnizar al comitente sea que los defectos deban atribuirse a su propia culpa o a la de sus empleados. Por personas que ocupa en la obra debe entenderse tanto los obreros directamente dependientes de él como los subcontratistas y personas que estos emplean.

Entendemos que en todos los supuestos la responsabilidad será de índole contractual, en tanto la responsabilidad por sus dependientes lo obliga frente al comitente, así como también conforme el artículo 1254 lo obliga respecto de los subcontratistas y demás intervinientes en la obra.

§ 2.— Obligaciones del comitente

437. Enumeración

Las obligaciones del dueño o comitente, conforme al artículo 1257, son: a) pagar la retribución; b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio; c) recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 1256.

A su vez, el comitente tendrá la obligación accesoria de pagar a todos aquellos que hayan participado en la obra o suministrado materiales si no les pagara el constructor.

1.— Modo de fijar el precio

438. Distintos modos de fijarlo

El precio de la obra puede ser fijado en una cantidad fija e invariable (ajuste alzado, o por unidad de medida), o puede fijarse una suma básica que variará según se modifiquen los precios de los materiales y de la mano de obra (coste y costos). Sobre el punto véanse números 738 y siguientes.

439. Caso en que no se haya establecido el precio

Si en el contrato no se hubiera fijado el precio, ni surgiera de los usos, se entenderá que las partes han contratado por ajuste alzado y que el contratista debe aportar los materiales (art. 1262, *in fine*). El precio será fijado judicialmente siguiendo las leyes arancelarias, los usos y costumbres vigentes y ponderando la extensión del trabajo realizado, pudiendo en caso de soluciones injustas apartarse de los mínimos y máximos legales (art. 1255).

2.— Momento del pago

440. Caso en que el contrato no lo establece

Si no hay tiempo estipulado, el pago del precio debe hacerse al tiempo de la entrega de la cosa. Equivale a la entrega, la aceptación expresa de la obra por el comitente que, por factores ajenos a la voluntad del contratista, la deja en su poder en calidad de depositario, etcétera.

441. Caso en que el contrato lo establece

Si el contrato establece el momento del pago, el comitente debe hacerlo en el término convenido. El comitente puede negarse a pagar el precio mientras no se le entregue la obra de acuerdo con lo convenido; es esta una mera aplicación de la *exceptio non adimpleti contractus*. Sin embargo, la jurisprudencia ha decidido, con razón, que las pequeñas deficiencias o defectos no autorizan al comitente a no pagar el precio, limitándose su derecho a deducir del precio pactado la suma necesaria para hacer las reparaciones. De lo contrario se incurriría en un evidente abuso de derecho.

442. Consecuencias de la falta de pago oportuno del precio

Si se hubiera convenido el pago por anticipado, el contratista puede abstenerse de dar comienzo a la obra y rechazar mediante la *exceptio non adimpleti contractus* toda pretensión del comitente para lograr el cumplimiento de la obra prometida. Puede también resolver el contrato por culpa del comitente, con la obligación de éste de

repararle los daños sufridos por el incumplimiento, para cuya estimación debe computarse no solo el daño emergente sino también el lucro cesante; es decir, toda la ganancia que esperaba de la obra.

Si se tratara de pagos periódicos, además de los derechos antedichos, el contratista puede suspender los trabajos y el plazo se considerará prorrogado por el tiempo que dure la demora del comitente.

Si se trata de pago al vencimiento, el contratista puede negarse a entregar la obra hasta que le sea pagada, haya o no provisto el comitente los materiales y sea o no dueño del suelo; a la inversa, el comitente puede negarse a pagar el precio mientras la cosa no sea entregada u ofrecida.

443. Derecho de retención

El contratista no pagado tiene derecho a retener la cosa sobre la cual ha realizado su obra (art. 2587).

En cuanto a los subcontratistas, solo pueden hacer uso de este derecho en caso de que tengan contra el comitente una acción directa, para lo cual es necesario que este último deba todo o parte del precio al contratista principal.

¿Se extiende el derecho de retención a los documentos, planos e instrumentos de trabajo proporcionados por el comitente? Prevalece la solución afirmativa; en el fondo, se trata de fortificar los recursos compulsivos que tiene a su disposición el contratista para obligar al comitente a cumplir con sus obligaciones.

3.— Lugar del pago

444. Aplicación de las reglas generales

El Código no contiene normas especiales sobre este punto. La solución del problema se encuentra en las reglas generales sobre pago.

Cuando no hay lugar designado en el contrato para el pago, el comitente tiene que hacerlo efectivo en el domicilio que tenía al tiempo del nacimiento de la obligación; sin perjuicio de ello, si el pago debiera coincidir con la recepción de la cosa, deberá hacerse donde deba cumplirse la prestación principal (art. 874).

4.— Revisión del precio

445. El problema

El contrato de obra se desenvuelve y cumple a través de un período de tiempo que a veces suele ser prolongado. Y no es difícil que durante él se produzca un encarecimiento

de los materiales y de la mano de obra; el contratista ve modificado así los valores con base en los cuales fijó el precio. No es difícil que pierda toda su ganancia y aun que sufra quebranto. Como tales variaciones se han hecho crónicas con motivo del estado de inflación en que se desenvuelve la economía contemporánea, los contratistas de obras importantes y de larga duración los celebran bajo el sistema de coste y costas, que les asegura el reconocimiento de los aumentos que se produzcan durante la realización de la obra siempre que no estuvieren en mora en la ejecución de los trabajos.

Bien entendido que no se podría pactar la repotenciación de todo el precio de la obra teniendo en cuenta el encarecimiento de uno de los materiales empleados (por ej., el cemento, el hierro, la madera), porque ello está prohibido por la ley 23.928; pero es legítimo pactar que si el precio estimado en el contrato para un determinado material aumenta en el momento de su inversión en la obra, se pagará ese mayor valor.

Supongamos ahora que el contrato no previera tales aumentos y que se hubiere acordado una suma fija (ajuste alzado). ¿Tiene derecho el contratista a pedir un aumento del precio fundado en la variación de los valores de los materiales y mano de obra? El Código Civil de Vélez resolvía el problema con un texto expreso y categórico: *bajo ningún pretexto* puede pedir aumento (art. 1633). El propósito de la ley era dar estabilidad y seguridad a los derechos adquiridos por el contrato; si las partes no previeron, como podían haberlo hecho, ninguna variación, es porque quisieron establecer desde el primer momento una suma fija y asumieron a designio el riesgo de una variación de precios. Si ellos disminuyen, el precio fijo favorecerá al contratista que de cualquier modo podrá cobrar la suma pactada; si aumentan, el precio contractual beneficiará al comitente.

Como principio, la solución era sin duda alguna razonable. Pero ocurre a veces que durante el curso del contrato se producen alteraciones verdaderamente imprevisibles del costo de la obra. ¿También en estos casos debía aplicarse rígidamente el artículo 1633 mencionado? Indudablemente, no. Es que si se tratara de aumentos determinados por circunstancias extraordinarias, imposibles de prever, debe reconocerse al contratista el derecho a una revisión del precio fijado en el contrato. Esta solución ha tenido expresa recepción legal en el artículo 1255 que –siguiendo la reforma introducida por la ley 17.711 al Código Civil de Vélez– luego de reiterar la regla del texto originario, agrega: *excepto lo dispuesto en el artículo 1091*. Esta última es la norma que consagra la teoría de la imprevisión. En otras palabras, cuando la variación del valor de la cosa ha sobrevenido como consecuencia de circunstancias extraordinarias e imprevisibles, hay derecho a reajuste.

Bien entendido que debe tratarse de acontecimientos imprevisibles. No tiene ese carácter, en una época de inflación, el aumento del valor de la mano de obra originado en un nuevo contrato colectivo de trabajo, ni el del precio de los materiales provocado por el aumento general de ellos, pues todo eso es perfectamente previsible. A menos, claro está, que la inflación, que ha seguido un curso más o menos constante, se desencadene de pronto a un ritmo acelerado y desquiciante. En tal supuesto juega también la teoría de la imprevisión.

446. Trabajos adicionales

Se vincula estrechamente con este problema el de los llamados trabajos adicionales. Es frecuente que durante la realización de la obra el comitente ordene modificaciones o añadidos respecto de los planos originarios. Está fuera de toda duda que tales trabajos deben ser remunerados con independencia del precio fijado para toda la obra, aunque esta se haya hecho por ajuste alzado. Los problemas que en la práctica se presentan son generalmente de prueba, pues muchas veces esos trabajos se ordenan verbalmente, en la confianza que suele originarse en un trato contractual prolongado. Luego, a la terminación de la obra, surgen las desavenencias.

El principio general es que todos los trabajos adicionales realizados fuera de las previsiones del contrato se encuentran comprendidos dentro del precio total pactado, a menos que el contratista pruebe que fueron ordenados por el comitente. Es necesario decidirlo así, porque de lo contrario, el contratista podría hacer modificaciones o agregados por propia decisión y con el propósito de recargar el precio. No tienen carácter de adicionales los trabajos que aunque no previstos expresamente eran necesarios para la realización de las obras según las reglas del arte y deben por tanto considerarse implícitamente comprendidas en ellas.

Sin embargo, la norma también ha puesto un límite a la potestad del comitente de introducir variantes, en tanto, ellas pueden derivar en una obra totalmente distinta a la convenida originalmente. Es por ello, que el artículo 1264 aclara que las variaciones del

comitente no pueden alterar sustancialmente la naturaleza de la obra.

Hasta aquí hemos hablado de los adicionales ordenados por el comitente. Pero hay que suponer también las variaciones ordenadas por el contratista. Como principio, carece por cierto de ese derecho: la ley dispone que el contratista no puede variar la obra sin permiso escrito del comitente. Pero si el cumplimiento del contrato exigiera esas alteraciones conforme a las reglas del arte, y ellas no pudieran preverse al tiempo que se concertó, deberá comunicarle de inmediato al comitente, expresando el impacto que tendrá sobre el precio fijado (art. 1264). Si las variaciones en el proyecto modifican el precio en más de una quinta parte, el comitente tendrá diez días para desistir de la obra. Se interpreta que el silencio, pasado ese lapso, presupone la aceptación del nuevo precio por parte del comitente.

447. ¿Tiene derecho el comitente a ordenar trabajos adicionales?

El problema se plantea en el supuesto de que el contrato no le conceda expresamente ese derecho. Mientras las modificaciones o alteraciones a la obra proyectada no hagan más onerosa la obligación del contratista, debe reconocerse la facultad del comitente de disponerlas y la obligación del contratista de acatar las órdenes recibidas; pero hay que hacer la excepción de la modificación de planos, que a juicio del arquitecto no podría ejecutar sin desmedro de su reputación profesional o artística; él no puede ser obligado a aceptar modificaciones que violenten su criterio estético o arquitectónico. Si las obras suponen una carga mayor para el constructor, el comitente no puede ordenarlas por acto unilateral; se requerirá, pues, la aquiescencia del contratista.

¿Y si las modificaciones hicieran más onerosa la obligación del contratista? En tal caso, *a falta de acuerdo, las diferencias de precio surgidas de las modificaciones autorizadas en este Capítulo (contrato de obra y servicios) se fijan judicialmente* (art. 1265).

5.— Prescripción

448. Plazo legal

La acción por cobro del precio prescribe por cinco años (art. 2560).

El plazo comienza a correr desde que el pago se ha hecho exigible; pero si se trata de varias cuotas, pensamos que cada una de ellas no tiene un comienzo propio y que todas empiezan a prescribir desde que la última cuota se ha hecho exigible.

B.

— OBLIGACIÓN DE COOPERACIÓN

449. Contenido

El comitente tiene la obligación de poner al contratista en condiciones de cumplir la obra. Es una obligación de contenido elástico: si se trata de una construcción sobre suelo, debe ponerlo en posesión de éste, proporcionarle los planos y los materiales e instrumentos de trabajos que hubiere prometido en el contrato; si para empezar la obra es necesario el consentimiento de un tercero o del Estado, debe gestionarlo y obtenerlo; tal ocurre, por ejemplo, con la aprobación de los planos por la administración local. Todo ello debe hacerlo en tiempo propio. Debe cumplir los actos de verificación sin demora; si de acuerdo con el contrato fuera necesaria su aprobación para los materiales o las distintas etapas de la obra, debe hacerlo en su momento. Está obligado a pagar puntualmente las cuotas pactadas.

Esta obligación tiene también un contenido negativo: el comitente debe abstenerse de todo acto personal que obstaculice o perturbe el normal desarrollo de los trabajos, como podría ser una fiscalización excesiva, que dificultara el normal desenvolvimiento de la obra.

450. Sanciones nacidas del incumplimiento de esta obligación

De lo dicho en el número anterior se desprende que el deber de cooperación no es una obligación única, sino una denominación que abraza obligaciones de distinta naturaleza e importancia. Por lo mismo, las sanciones no pueden ser en todos los casos las mismas sino que deben adecuarse a su gravedad. Sin embargo, hay un recurso que sirve de común denominador y que puede ser siempre esgrimido por el contratista para obligar al comitente a cumplir: la *exceptio non adimpleti contractus*. Solo debe exceptuarse el caso de que la inejecución del comitente fuera de tan escasa importancia, que el contratista no podría negarse a cumplir con las obligaciones a su cargo sin manifiesta violación del principio de la buena fe que debe regir las relaciones contractuales. En consecuencia, y salvo la situación de excepción antedicha, cuando el comitente incurre en algún incumplimiento de sus deberes de cooperación, el contratista puede suspender la continuación de la obra.

En ciertos casos, puede incluso pedir la resolución del contrato por culpa del comitente. Sin embargo, una pequeña demora que no perjudica al contratista, no justificaría la acción de resolución.

C.

— OBLIGACIÓN DE RECIBIR LA OBRA

451. Recepción

Terminada la obra, el contratista está obligado a entregarla y el comitente a recibirla (ver 795).

D. — OBLIGACIÓN CONDICIONAL DE PAGAR A LOS OBREROS Y PROVEEDORES DE MATERIALES CONTRATADOS POR EL CONTRATISTA

452. Condiciones para el ejercicio de esta acción

En principio, ni los obreros contratados por el contratista ni los proveedores que le vendieron materiales tienen acción por cobro de sus créditos contra el comitente. Es justo que así sea, porque ellos han contratado con el contratista y no con el comitente, que nada les debe. Pero si el comitente no hubiera pagado todavía al contratista la totalidad del precio pactado, entonces los obreros y proveedores tienen acción directa contra él hasta la concurrencia de la suma debida al contratista (art. 736). Es una

solución fundada en razones de equidad.

Si bien esta posibilidad era contemplada expresamente en el artículo 1645 del Código Civil de Vélez, su derogación no hace desaparecer la acción que éste establecía, en tanto ellas siguen vigentes mediante la regulación general de la acción directa contenida en los artículos 736 y siguientes del Código Civil y Comercial.

Reconocer la existencia de una acción directa (y no subrogatoria) es de la mayor importancia en caso de concurso o quiebra del contratista, pues de esta manera, los acreedores pueden cobrar sus créditos del comitente, sin pasar por la masa del fallido.

453. Quiénes gozan de ella

Desde que la acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito (art. 736), cualquier acreedor del contratista podrá accionar contra el comitente, en los límites que los artículos 736 y siguientes imponen. Así, quedan incluidos los proveedores del contratista, el subcontratista, los obreros, etcétera.

454. Prueba de los pagos hechos por el comitente al contratista; recibos privados sin fecha cierta

La acción procede, ya lo hemos dicho, solo en la medida de la deuda que el comitente tenga pendiente en favor del contratista. Como los obreros y proveedores normalmente no tienen posibilidad de munirse de la prueba de que aún existe un saldo pendiente de pago, ellos pueden intentar la acción directa sin más ni más. Es al comitente al que corresponde producir la prueba de los pagos que ha realizado al contratista.

¿Son suficientes para tener por demostrados esos pagos los recibos privados emanados del contratista, sin fecha cierta? Algunos fallos y autores se han pronunciado por la solución negativa: se fundan en el artículo 317 según el cual los instrumentos privados no prueban contra terceros la verdad de la fecha expresada en ellos; agregan todavía que siendo esta una acción directa, los obreros y proveedores no actúan en nombre del contratista (en cuyo caso sí podrían serles opuestos tales recibos), sino como terceros munidos de una acción propia a quienes se aplica el mencionado artículo 317.

Por nuestra parte, estamos lejos de admitir tal solución que conduce a resultados injustísimos. Si los recibos privados otorgados por el contratista no probaran la verdad respecto de los obreros y proveedores, todos los recibos por pagos parciales deberían otorgarse por escritura pública, única manera que tiene el comitente de evitar luego la sorpresa de una acción que lo obligue a pagar dos veces. Está de más decir que tal modo de extender los recibos es extremadamente impráctico y contrario a nuestras costumbres; los recibos por pagos parciales del precio se otorgan siempre en forma privada. Pensamos pues que el recibo privado puede oponerse a obreros y

subcontratistas siempre que se refiera a trabajos ya hechos y no a pagos anticipados; en este caso, el pago anticipado acreditado en forma privada sin fecha cierta, crea una fuerte sospecha de colusión en perjuicio de los obreros, que obliga a desestimar tal prueba.

§ 3.— Responsabilidad de las partes ante terceros

455. Responsabilidad del contratista y de otras personas que intervienen en la construcción

Según el artículo 1277, no solo los contratistas son responsables por la inobservancia de las disposiciones legales y de todo daño que causen a los vecinos, sino que esta responsabilidad se extiende en forma solidaria a todos los subcontratistas y profesionales que hayan intervenido en la obra.

a) Con respecto a los *vecinos*, no solo son responsables de los daños que se les deriven de la inobservancia de las reglamentaciones municipales o cualquier otra disposición legal (paredes construidas en contravención que oscurecen la finca vecina; techos que echan las aguas pluviales sobre el vecino, etc.), sino también de todo daño

que por su culpa o la de sus dependientes resulte para ellos, aunque no medie inobservancia de las reglamentaciones municipales, como, por ejemplo, el derrumbe o rajadura de una pared medianera como consecuencia de la excavación, destrozos ocasionados por las caídas de instrumentos de trabajo o de mampostería, etcétera.

b) Con respecto a otros *terceros*, responden también de todos los daños que se les deriven de su culpa o de la de sus dependientes, como, por ejemplo, si la caída de un instrumento de trabajo o de materiales de construcción provoca heridas o la muerte de un transeúnte.

c) Respecto de la *Administración Pública*, es responsable de la inobservancia de leyes y reglamentos; esa sanción se traduce generalmente en el pago de multas y la obligación de destruir lo realizado en contravención.

d) Con respecto al *comitente*, ya hemos dicho cuál es el alcance de su responsabilidad contractual (véanse nros. 757 y ss.), la que no excluye la derivada de la comisión de algún hecho ilícito del cual resulte perjuicio para aquel.

456. Responsabilidad del comitente

La responsabilidad que la ley reconoce al contratista frente a terceros, ¿excluye la del comitente? Veamos.

a) Si se trata de los perjuicios ocasionados a los vecinos por la inobservancia de las reglamentaciones municipales, nos inclinamos a creer que la responsabilidad es exclusiva del contratista. El artículo 1277 no menciona al comitente. Por iguales motivos, debe considerarse que este último carece de responsabilidad ante la administración por la inobservancia de las reglamentaciones en que incurrió el contratista.

b) Si se trata de perjuicios ocasionados a los terceros y vecinos por culpa personal del contratista o sus obreros, el comitente responde junto con el contratista en el caso de que el daño se hubiera hecho con una cosa de su propiedad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1758.

§ 2.— Fin del contrato

457. Enumeración

El contrato de obra se extingue: a) por el cumplimiento de la obra y el pago del precio; b) por desistimiento del comitente; c) por muerte, desaparición o falencia del contratista; d) por imposibilidad del contratista de hacer o terminar la obra; e) por voluntad de una de las partes fundada en el incumplimiento de la otra. Si la obra se ha contratado por pieza o medida, sin designación del número de piezas o de la medida total, el contrato puede resolverse por una y otra parte concluida que sea cada una de las piezas o partes designadas.

A estos medios propios de extinción de este contrato, hay que añadir otros que son generales, a saber: rescisión por mutuo consentimiento y confusión de la persona del comitente y contratista.

A. — CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. — Recepción de la obra

795. Diligencias previas; la verificación

La forma normal de la conclusión del contrato de obra es su cumplimiento por ambas partes; es decir, la entrega de la obra concluida y el pago del precio.

El acto esencial de esta etapa final del contrato es la recepción de la obra por el comitente. Pero éste no puede ser obligado a recibir la obra sin antes haber verificado si llena las condiciones exigidas en el contrato. Por consiguiente, el contratista debe dar aviso al comitente una vez terminada la obra, para que pueda realizar la verificación, a cuyo fin debe contar con un tiempo razonable.

La verificación es un derecho y no una obligación del comitente; el contratista cumple poniendo la cosa a su disposición durante un tiempo razonable, vencido el cual puede exigir al comitente que reciba la cosa.

796. Aceptación y recepción

La aceptación es la manifestación de la conformidad del comitente con la obra realizada; la recepción es la toma voluntaria de la obra de manos del contratista. Son actos distintos, pero estrechamente ligados. Por lo común ocurren en un solo momento: cuando el comitente recibe la obra, ya que este acto implica la aceptación tácita. Pero pueden no coincidir. Así ocurre cuando el comitente acepta la cosa, pero la deja en poder del contratista (aceptación sin recepción) o cuando la recibe con reserva (recepción sin aceptación).

2.— Efectos de la recepción

797. Recepción de la obra sin reservas

La recepción de la obra por el comitente, sin formular reserva alguna, produce los siguientes efectos:

a) Plazo

Si ha habido demoras en la terminación y entrega, la recepción implica la concesión tácita de un plazo; el comitente no podrá en adelante pretender ninguna indemnización por este concepto.

b) Trabajos adicionales

Si se han realizado trabajos adicionales, la recepción implica el reconocimiento de que fueron hechos con la autorización del comitente, quien está obligado a pagarlos.

c) Vicios aparentes

El comitente pierde el derecho a reclamar por la existencia de vicios aparentes (arts. 747 y 1272, inc. a)], a menos que ellos sean causa de la ruina de la obra.

Por vicios aparentes debe entenderse aquellos que son de fácil comprobación, tal como el estado de la pintura y revoques, tabiques divisorios que no están conformes con los planos, falta de cumplimiento de las estipulaciones relativas a la calidad de los pisos, etcétera.

Esta norma no se aplica en los supuestos de contrataciones de obra en el marco de una relación de consumo, en tanto el proveedor responde también por los vicios aparentes por un plazo de 30 días desde la recepción de la obra (art. 23, ley 24.240).

d) Vicios ocultos

El artículo 1272, inciso b), remite a la regulación general sobre vicios ocultos para los defectos que se manifestaren en la obra.

Así, y por imperio de los artículos 1054 y 1055, se establecen dos plazos de caducidad de la acción.

El primero de ellos es de 60 días, dentro de los cuales el comitente debe notificar en forma fehaciente al contratista de la aparición del vicio, bajo apercibimiento de perder la garantía (art. 1054).

El segundo, es de tres años o de seis meses, según se trate de cosa inmueble o mueble, dentro de los cuales debe manifestarse el vicio para estar garantizado por el comitente, plazo que se computa desde la recepción de la obra en ambos supuestos o, además, en el caso de los muebles, desde que se los puso en funcionamiento (art. 1055).

Si el vicio es notorio dentro de los plazos señalados precedentemente, y se notifica dentro de los 60 días al contratista, comienza a correr el plazo de prescripción de la acción desde esa notificación, plazo que es de un año (art. 2564, inc. a)).

No está de más señalar que, de manera general, *las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de la obra* (art. 1271).

798. Recepción provisoria

Algunos contratos contienen una cláusula en virtud de la cual al término de la obra, el comitente la recibirá *provisionalmente*; recién después de transcurrido un cierto lapso, se produce la recepción definitiva. Durante ese período, el comitente tiene derecho a retener del precio adeudado un depósito de garantía, que sirve para responder a las reparaciones que eventualmente sea necesario realizar por vicios ocultos de la cosa.

En los contratos de obras públicas regidas por la ley 13.064 la recepción debe hacerse siempre en forma provisional; la recepción definitiva se lleva a cabo luego de un plazo que se fija en cada caso, durante el cual el contratista corre con los gastos de conservación y reparación de las obras, salvo los defectos resultantes del uso indebido (art. 41). El depósito de garantía se entregará al contratista recién al recibir definitivamente la obra (art. 44).

1. — Muerte del contratista

801. Resolución del contrato

La muerte del contratista resuelve el contrato, no así —al menos, como regla— la del comitente (arts. 1259 y 1260). La solución es lógica, porque la persona del contratista es generalmente decisiva en el contrato de obra, en tanto que la del comitente es casi siempre indiferente.

El fallecimiento del contratista pone fin al contrato sin necesidad de que la resolución sea pedida por los herederos.

Hemos dicho que la muerte del comitente no extingue, como regla, el contrato. Por excepción, sí lo hace, cuando su muerte hace imposible o inútil la ejecución de la obra (art. 1260).

802. Efectos de la resolución del contrato

Resuelto el contrato por fallecimiento del contratista, el comitente debe pagar a los herederos de aquél, el costo de los materiales aprovechables y, en proporción del precio convenido, el valor de la parte de la obra ejecutada (art. 1260). Con respecto a la obra ejecutada, no interesa si ella es o no útil al comitente, siempre que haya sido ejecutada de acuerdo con las estipulaciones del contrato. Los materiales, en cambio, solo deben pagarse en la medida en que sean útiles a la obra. Es natural que sea así. Si el contratista ha acumulado más materiales de los que eran necesarios o ellos son defectuosos o inapropiados para la obra, no tiene el comitente por qué pagarlos. Va de suyo que los materiales no pagados por el comitente pueden ser retirados por los herederos.

2.— Desaparición del empresario

803. Desaparición del empresario y abandono de la obra

Disponía el artículo 1643 del Código Civil de Vélez que el contrato puede ser resuelto por el comitente si desaparece el empresario. Por desaparición debe entenderse un

abandono total de la obra, con la consiguiente cesación de los trabajos. Sin embargo, también se consideraba que había abandono de la obra por el contratista, cuando éste ejecutaba los trabajos con una lentitud tal que fuera imposible completarlos en el plazo estipulado. En ambos supuestos, el comitente estaba facultado para resolver el contrato.

Esta causal de extinción del contrato no es mencionada en el Código Civil y Comercial; sin embargo, ella queda subsumida en la genérica causal de resolución contractual por incumplimiento de las obligaciones.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe recordarse que la ley de obras públicas hace referencia concreta al abandono de la obra, pues dispone que habrá abandono que autoriza al Estado a resolver el contrato cuando los trabajos se realicen con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de la administración no puedan terminarse en los plazos estipulados; y cuando el contratista interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones o por plazo mayor de un mes, aunque sea una sola vez (art. 50, incs. b) y e], ley 13.064).

3.— Quiebra

804. Quiebra del contratista

El comitente tiene derecho a pedir la resolución del contrato cuando el contratista ha caído en quiebra (art. 143, inc. 2º, ley 24.522). Es una facultad de la que hará uso según le convenga. Así, por ejemplo, es casi seguro que la ejercerá si la obra consiste en la construcción de un edificio, pues la quiebra del contratista lo coloca prácticamente en la imposibilidad de continuar los trabajos por falta de crédito, sin contar con que al comitente no le conviene la ejecución de la obra por una persona insolvente, contra la cual no podrá luego hacer efectiva la responsabilidad por los vicios o defectos. Si, en cambio, se trata de un retrato encargado a un pintor, es obvio que la falencia no le impedirá cumplir su promesa y el comitente no tendrá interés en la resolución.

Para que el comitente tenga derecho a optar por la resolución, no es suficiente el concurso preventivo de acreedores, pues durante la tramitación del concordato, el deudor conserva la administración de sus bienes y prosigue las operaciones ordinarias de su comercio o industria bajo vigilancia del síndico (art. 15, ley 24.522).

Según el artículo 144, ley 24.522, el comitente debe hacer saber su decisión de continuar o resolver el contrato dentro de los veinte días de la publicación de edictos,

luego debe oírse al síndico quien opinará sobre la continuación o resolución del contrato. Finalmente, el juez dictará la resolución correspondiente, que solo es apelable por el comitente cuando se hubiese opuesto a la continuación.

805. Quiebra del comitente

La solución dada por los artículos 15 y 144 de la ley 24.522, es aplicable a los casos de concurso y quiebra del comitente. Independientemente de ese recurso, el contratista está protegido por el derecho de retención que le reconoce el artículo 2587 y el privilegio para los gastos de la construcción del artículo 2582, inciso a).

Es claro que si el precio hubiera sido pagado por anticipado, no podrá ya el contratista negarse a continuar la obra so pretexto de quiebra del comitente. Tampoco puede negarse a cumplir sus compromisos si la masa le afianza satisfactoriamente el pago del precio.

C. — IMPOSIBILIDAD DEL CONTRATISTA DE HACER O TERMINAR LA OBRA

806. Concepto de imposibilidad

Disponía el artículo 1642 del Código Civil de Vélez que el contrato puede ser resuelto por el comitente o por el contratista cuando sobreviene a éste imposibilidad de hacer o de concluir la obra. La imposibilidad puede ser objetiva o subjetiva. La primera es aquella que deriva de acontecimientos externos a las partes, tales como la expropiación del inmueble en que se ha de realizar la obra, la destrucción de la cosa por un accidente, un rayo, etc. La imposibilidad subjetiva es la que se refiere a la persona misma del contratista; por ejemplo, que enloquezca o enferme gravemente o sea condenado a prisión o movilizad por guerra interna o externa. La resolución del contrato en estos casos es una simple aplicación de los principios que rigen el incumplimiento derivado de caso fortuito o de fuerza mayor.

No debe asimilarse la imposibilidad de cumplir con la dificultad de hacerlo. No porque su prestación devenga más onerosa queda eximido el contratista de su obligación de cumplirla; todo lo más, si la mayor onerosidad proviniera de causas extraordinarias e imprevisibles, tendrá derecho a exigir una revisión del precio pactado (véase nro. 780). Es necesario agregar, sin embargo, que aunque teóricamente los conceptos de imposibilidad y dificultad de realización son claramente diferenciables, hay, empero, una

zona de contacto en que la distinción no resulta clara. Así, por ejemplo, la enfermedad que padece el contratista, ¿es de tal gravedad que lo imposibilita para continuar la obra o simplemente le hace más difícil cumplirla? En esa zona gris, el juez deberá resolver el problema según su prudente arbitrio.

En el Código Civil y Comercial, la solución es similar, pero resulta de la aplicación de las normas referidas a la extinción por imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones.

807. Efectos de la imposibilidad

La imposibilidad de continuar la obra produce siempre la resolución del contrato, cualquiera que sea la causa de la que aquella derive. Pero con relación a los restantes efectos, es necesario distinguir tres situaciones:

a) Imposibilidad sobrevenida sin culpa de las partes

El contrato queda resuelto y el comitente está obligado a pagar la obra ya realizada en proporción a lo hecho y al precio pactado (art. 1267). Así ocurrirá si la cosa ha sido expropiada por el Estado o si el contratista ha enloquecido o ha sido movilizado por una acción militar. Pero, teniendo en cuenta que la obligación del contratista es de resultado, a él le incumbe la prueba del caso fortuito o de la fuerza mayor que lo libere.

b) Imposibilidad derivada de culpa del contratista

El contratista deberá pagar al comitente todos los daños y perjuicios que le resulten de la resolución. Así ocurrirá si el contratista ha sido condenado a prisión por la comisión de un delito; pero no habrá culpa de su parte si ha sido procesado y detenido aunque sea por largo tiempo y luego se lo declara inocente. Muy dudoso es el supuesto de que el contratista se enrola voluntariamente en el ejército con motivo de un peligro de guerra, no obstante no estar obligado a hacerlo. Aunque estrictamente la imposibilidad sobrevenida le es imputable, lo cierto es que se ha enrolado respondiendo a un noble sentimiento patriótico; planteado el caso, difícilmente los tribunales lo condenen al pago de los daños sufridos por el comitente por el incumplimiento.

c) Imposibilidad derivada de culpa del comitente

El comitente responderá por todos los daños que se le deriven de la resolución del contrato al contratista, inclusive todas las ganancias que esperaba obtener de la obra. Como ejemplos de este supuesto, podemos señalar la expropiación gestionada por el

comitente del inmueble, la reivindicación del inmueble por un tercero con mejor derecho, etcétera.

808. Imposibilidad temporaria; efectos

La imposibilidad puede ser meramente temporaria; así, por ejemplo, una huelga de transportes que impide la provisión de los materiales encargados para la obra, una enfermedad pasajera del contratista, etc. En principio, esta imposibilidad no da lugar a la resolución del contrato, sino a una prórroga del plazo por un período equivalente al de la imposibilidad. En cuanto a los daños derivados de la prolongación de la obra, habrá que distinguir, como en el caso de la imposibilidad absoluta, entre el impedimento ocurrido sin culpa de las partes y el que deriva de la culpa del comitente o contratista. En el primer caso, no habrá lugar a indemnización de los daños; en el segundo, la parte culpable deberá responder ante la otra de los perjuicios que la demora le haya ocasionado.

D. — INEJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR UNA DE LAS PARTES

809. El pacto comisorio es tácito en el contrato de obra

La inejecución de sus obligaciones por una de las partes permite a la otra pedir la resolución del contrato; en el contrato de obra, la cláusula resolutoria (pacto comisorio) es implícita o tácita.

En cuanto al incumplimiento del comitente, el contrato puede ser resuelto por el contratista porque el comitente no dio los materiales prometidos o porque no pagó las prestaciones convenidas.

En cuanto al incumplimiento del contratista, el comitente tiene derecho a pedir la resolución del contrato cuando abandona la obra o cuando la ejecuta en forma deficiente. El mismo derecho lo tiene cuando el contratista, apartándose del límite de gasto fijado por el comitente en el contrato celebrado y en las bases del concurso de anteproyectos al cual se habían presentado, presenta un presupuesto superior intentando justificar el excedente en el gasto.

Naturalmente, no cualquier incumplimiento autoriza la resolución; así, por ejemplo, una pequeña demora en la provisión de los materiales por el comitente o en la ejecución de las obras por el contratista. Debe tratarse de un incumplimiento grave, sin lo cual la pretensión de la parte que pide la resolución sería abusiva.

Código Civil y Comercial de la Nación

ARTICULO 1251.- Definición. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución.

El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.

ARTICULO 1252.- Calificación del contrato. Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega.

Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral.

Las disposiciones de este Capítulo se integran con las reglas específicas que resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados.

ARTICULO 1253.- Medios utilizados. A falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, el contratista o prestador de los servicios elige libremente los medios de ejecución del contrato.

ARTICULO 1254.- Cooperación de terceros. El contratista o prestador de servicios puede valerse de terceros para ejecutar el servicio, excepto que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personalmente en todo o en parte. En cualquier caso, conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución.

ARTICULO 1255.- Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial.

Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución.

Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con fundamento en que la obra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el artículo 1091.

ARTICULO 1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a:

- a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;
- b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida;
- c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos;
- d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese

conocer;

e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.

ARTICULO 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a:

- a) pagar la retribución;
- b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio;
- c) recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 1256.

ARTICULO 1258.- Riesgos de la contratación. Si los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del servicio perecen por fuerza mayor, la pérdida la soporta la parte que debía proveerlos.

ARTICULO 1259.- Muerte del comitente. La muerte del comitente no extingue el contrato, excepto que haga imposible o inútil la ejecución.

ARTICULO 1260.- Muerte del contratista o prestador. La muerte del contratista o prestador extingue el contrato, excepto que el comitente acuerde continuarlo con los herederos de aquél. En caso de extinción, el comitente debe pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte realizada en proporción al precio total convenido.

ARTICULO 1261.- Desistimiento unilateral. El comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia.

Disposiciones especiales para las obras

ARTICULO 1262.- Sistemas de contratación. La obra puede ser contratada por ajuste alzado, también denominado "retribución global", por unidad de medida, por coste y costas o por cualquier otro sistema convenido por las partes. La contratación puede hacerse con o sin provisión de materiales por el comitente. Si se trata de inmuebles, la obra puede realizarse en terreno del comitente o de un tercero. Si nada se convino ni surge de los usos, se presume, excepto prueba en contrario, que la obra fue contratada por ajuste alzado y que es el contratista quien provee los materiales.

ARTICULO 1263.- Retribución. Si la obra se contrata por el sistema de ejecución a coste y costas, la retribución se determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos o indirectos.

ARTICULO 1264.- Variaciones del proyecto convenido. Cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser previstas al momento de la contratación; la necesidad de tales modificaciones debe ser comunicada inmediatamente al comitente con indicación de su costo estimado. Si las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguirlo comunicando su decisión dentro del plazo de diez días de haber conocido la necesidad de la modificación y su costo estimado.

El comitente puede introducir variantes al proyecto siempre que no impliquen cambiar sustancialmente la naturaleza de la obra.

ARTICULO 1265.- Diferencias de retribución surgidas de modificaciones autorizadas. A falta de acuerdo, las diferencias de precio surgidas de las modificaciones autorizadas en este Capítulo se fijan judicialmente.

ARTICULO 1266.- Obra por pieza o medida. Si la obra fue pactada por pieza o medida sin

designación del número de piezas o de la medida total, el contrato puede ser extinguido por cualquiera de los contratantes concluidas que sean las partes designadas como límite mínimo, debiéndose las prestaciones correspondientes a la parte concluida.

Si se ha designado el número de piezas o la medida total, el contratista está obligado a entregar la obra concluida y el comitente a pagar la retribución que resulte del total de las unidades pactadas.

ARTICULO 1267.- Imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa. Si la ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por causa no imputable a ninguna de las partes, el contrato se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa por la tarea efectuada.

ARTICULO 1268.- Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega. La destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato, con los siguientes efectos:

- a) si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada;
- b) si la causa de la destrucción o del deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no se debe la remuneración pactada aunque el contratista haya advertido oportunamente esa circunstancia al comitente;
- c) si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada.

ARTICULO 1269.- Derecho a verificar. En todo momento, y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados.

ARTICULO 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747.

ARTICULO 1271.- Vicios o defectos y diferencias en la calidad. Las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de la obra.

ARTICULO 1272. Plazos de garantía. Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación.

Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, no se pactó un plazo de garantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista:

- a) queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes;
- b) responde de los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, con la extensión y en los plazos previstos para la garantía por vicios ocultos prevista en los artículos 1054 y concordantes.

ARTICULO 1273.- Obra en ruina o impropia para su destino. El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista.

ARTICULO 1274.- Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino. La responsabilidad prevista en el artículo 1273 se extiende concurrentemente:

- a) a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual;

b) a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista;

c) según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes.

ARTICULO 1275.- Plazo de caducidad. Para que sea aplicable la responsabilidad prevista en los artículos 1273 y 1274, el daño debe producirse dentro de los diez años de aceptada la obra.

ARTICULO 1276.- Nulidad de la cláusula de exclusión o limitación de la responsabilidad. Toda cláusula que dispensa o limita la responsabilidad prevista para los daños que comprometen la solidez de una obra realizada en inmueble destinada a larga duración o que la hacen impropia para su destino, se tiene por no escrita.

ARTICULO 1277.- Responsabilidades complementarias. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones.